

1503129-48.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Jadson já era pessoa conhecida no tráfico. Marcos foi a primeira vez, embora já tenha sido visto na localidade, que é conhecida como ponto de tráfico. Não havia denúncia específica acerca da pessoa dos Réus. A localidade é conhecida como ponto de tráfico e foi uma operação de rotina. Em poucos minutos de campana já foi possível presenciar a venda de droga para um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503129-48.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503129-48.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259579/2021 - 01º D.P. CUBATÃO, 20421076 - 01º D.P. CUBATÃO, 550/21/228 - 01º D.P. CUBATÃO, 2259579 - 01º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS ARAÚJO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

I - RELATÓRIO

MARCOS ARAÚJO DOS SANTOS e JADSON PAULO DA SILVA foram denunciados e estão sendo processados por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006. Isto porque, segundo a denúncia, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 10h00, na Rua Santa Teresinha, na Travessa Santo Antônio de Pádua, Vila São Jorge, Cubatão, MARCOS ARAÚJO DOS SANTOS, qualificado a fls. 13, e JADSON PAULO DA SILVA, qualificado a fls. 69, agindo previamente ajustados, com identidade de propósitos, desígnios e divisão de tarefas, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros substâncias entorpecentes, maconha, cocaína e "crack", causadoras de

dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 08, auto de constatação preliminar de fls. 50/51 e laudo definitivo das drogas de fls. 74/76. Segundo o apurado, policiais civis, durante atuação de campo, em uma viatura descaracterizada, realizaram uma breve campanha, no local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, e perceberam a presença do denunciado JADSON, velho conhecido, por ter sido preso, anteriormente, em flagrante, pelo delito de tráfico de entorpecentes, além do denunciado MARCOS. Em seguida, visualizaram um usuário de droga se aproximando, sendo possível notar que o denunciado JADSON retirou, do interior, de uma sacola plástica, algo que, aparentemente, seria entorpecente, entregando ao indivíduo, enquanto o denunciado MARCOS, em conluio, com nítida divisão de tarefas, permanecia observando, atentamente, a movimentação, ao redor. Em dado momento, ao se aproximarem dos indivíduos, o denunciado MARCOS, imediatamente, passou a gritar: "é polícia, é polícia", instante em que JADSON dispensou a sacola que portava, passando a correr, ao passo que o usuário, que havia recebido algo, fugiu para o lado oposto, sendo detido, apenas, MARCOS. Em revista, no interior da sacola plástica dispensada por JADSON, lograram êxito em localizar, em seu interior, 26 porções de maconha (peso bruto - 90g), 58 pedras de "crack" (peso bruto - 35g) e 148 pinos contendo cocaína (peso bruto - 230g). A grande quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento (fracionadas e previamente embaladas, prontas para o comércio), as circunstâncias da apreensão e os testemunhos dos policiais, demonstram que os denunciados praticavam, em conluio, o tráfico ilícito de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2021 (fls. 91/99).

Os acusados foram citados e apresentaram defesa prévia (fls. 234-238 e fls. 248-249). Juntada folha de antecedente do Marcos em fls. 28/29 e Jadson fls. 119/120. Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas. Ao final, os réus foram interrogados.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a aplicação de regime inicial diverso do fechado, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, para o Réu Marcos, desclassificação para a conduta do art. 37 da Lei de Drogas.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório dos acusados.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Inicialmente, gizo que incabível a alegação de que o flagrante foi preparado.

O flagrante provocado ou preparado é aquele em que ocorre a indução ou instigação para que agente cometa o crime, com o fito de se efetuar a prisão. Como ensina RENATO BRASILEIRO DE LIMA, o flagrante preparado, também chamado de provocado, crime de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador, "ocorre quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consuma". (Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1.035.) A atuação dos policiais, como se vê, não se amolda à figura do flagrante preparado, mas sim ao que na doutrina convencionou-se chamar de flagrante esperado, em que, "valendo-se de investigação anterior, sem a utilização de um agente provocador, a autoridade policial ou terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante" (Manual de Processo Penal. 8ª ed.

Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1.036).

Assim, dos fatos narrados restou evidente que não houve qualquer tipo de preparação dos agentes policiais para que os Réus cometessem o crime. Não houve qualquer provocação escrupulosamente engengrada, a ensejar o nascedouro ou a gênese da intenção ou volição dos Réus para a prática ou consecução das condutas. Ao contrário, os agentes policiais estavam em patrulhamento e perceberam a ocorrência. Em verdade, o que poderia ter no caso em tela, é um verdadeiro flagrante diferido (ação controlada), conforme previsão contida no art. 53, inc. II da Lei 11.343/06 e no art. 3º, inc. III da Lei nº 12.850/2013. Afinal, esta modalidade de obtenção probatória consiste "em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações" (art. 8º da Lei 12.850/2013).

Logo, o crime – que é permanente – já estava sendo praticado antes mesmo da chegada dos policiais. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça que se aplica perfeitamente à espécie:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ QUE SE CONFUNDIR FLAGRANTE PREPARADO COM FLAGRANTE ESPERADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. 1. Não se deve confundir flagrante preparado com esperado – em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração. 2. A 'campana' realizada pelos policiais a espera dos fatos não se amolda à figura do flagrante preparado, porquanto não houve a instigação e tampouco a preparação do ato, mas apenas o exercício pelos milicianos de vigilância na conduta do agente criminoso tão-somente a espera da prática da infração penal. (...) 6. Writ denegado (HC 40.436/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 02/05/2006, p. 343).

Ademais, não há quaisquer nulidades quanto a prisão em flagrante, posto que a mesma já fora analisada na audiência de custódia, sendo inclusive homologada. Ultrapassada essa questão prévia, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III – MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC – e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP – passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

Consente-se que simbolicamente a Lei 11.343, que revogou a Lei 6.368/76 “representa uma nova política na seara das drogas” (HASSON, Felipe. Drogas: Constituição, Democracia e Liberdade. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2015.p. 156).

Na seara do Direito Penal, afirmam Zaffaroni e Pierangelli: “todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem a suas regulações. Portanto, também, o direito penal tem uma aspiração ética: aspira evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados” (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2013. p. 95).

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp. 1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição/apreensão (fls. 08), termo de depoimento (fls. 09/11), relatório final (fls. 103/104 e 112/113), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição aos réus, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Demais, adotando-se o conceito complexo do tipo de Hans Welzel, tem-se que ele apresenta um aspecto objetivo e outro subjetivo. Na ação penal típica, está implícito um juízo de valor. O tipo penal, deste modo, não é composto apenas por elementos objetivos, mas é também integrado por elementos normativos e subjetivos, que vão contornando o conteúdo material do injusto e identificando o bem jurídico tutelado. Em síntese, é a efetiva lesão ao bem jurídico que conduz o intérprete nos caminhos na tipicidade, como se minudenciaria.

Vejamos:

Em solo policial, a testemunha ALBINO ARIAS COSTA disse que "Que, também é policial civil em exercício na chefia do 01º Distrito Policial de Cubatão. Afirmando que na data de hoje estavam em operação pelo Deinter 6, visando o combate ao tráfico de drogas na região, foram até o local dos fatos, este de conhecida prática de tráfico de entorpecentes, visto que em datas pretéritas já foram realizadas diversas prisões naquele local pela prática do referido crime. Que ao chegarem ao local em uma viatura descaracterizada, permaneceram de forma velada sem levantar suspeitas, há cerca de trinta metros aproximadamente observando o movimento no local, onde já haviam dois indivíduos parados, porém afastados um do outro, sendo que um deles de nome Jadson, já é um velho conhecido dos policiais, por motivos de ter sido autuado em flagrante delito anteriormente pela prática de tráfico de drogas e o outro trata-se do indiciado Marcos. Que, enquanto observavam a movimentação no local, um terceiro indivíduo se aproximou de Jadson, o qual retirou do interior de uma sacola plástica algo que aparentemente seria entorpecentes e deu ao indivíduo, momento em que decidiram proceder com a abordagem dos suspeitos, entretanto, o indiciado Marcos que estava mais afastado de Jadson, ao ver a aproximação do depoente e seu parceiro, gritou as seguintes palavras "é polícia, é polícia", instante em que Jadson que estava com a sacola em mãos acabou dispensando a sacola no chão e passou a correr e, o outro indivíduo desconhecido que seria o usuário também conseguiu correr em sentido contrário ao do primeiro e, ambos conseguiram se evadir do local, sendo que Marcos o indivíduo que anunciou a chegada dos policiais tentou se evadir de forma dissimulada, como se nada tivesse acontecido, porém foi contido ali mesmo no local. Que, ao verificarem o interior da sacola plástica dispensada por Jadson, encontraram os entorpecentes relacionados no boletim de ocorrências, os quais estavam todos embalados em pequenas porções e prontos para a venda em varejo. Que, ainda pelo local dos fatos, indagaram Marcos Araújo dos Santos, porque delatou a chegada dos policiais, tendo o mesmo informado que é usuário de drogas e que na data de hoje ao ir comprar entorpecentes, recebeu a proposta de um indivíduo de vulgo "neguinho", demais dados não sabe informar, o qual estava naquele local, e disse que precisava se ausentar para tomar um café rápido e que era para ele ficar observando uma eventual chegada de policiais e gritar avisando, sendo que receberia a quantia de dez reais para isso, tendo aceitado a proposta e enquanto estava no local a polícia chegou e conforme combinado gritou avisando da chegada da polícia e, ao tentar sair do local, foi detido e trazido para delegacia. Que diante dos fatos, Marcos Araújo dos Santos, foi conduzido até esta delegacia, bem como os entorpecentes deixados no local por Jadson. Que, realizaram buscas durante o registro da ocorrência na tentativa de localizar Jadson, porém até o término do registro não foi possível sua localização" (fls. 11).

Em Juízo, disse que se recorda dos fatos e de ambos os Réus, inclusive reconhecendo Jadson mesmo com o uso de máscara facial. Jadson já era pessoa conhecida pela narcotraficância. O modus operandi era também conhecido como da facção. Por conta do horário, utilizam olheiros. Jadson estava substituindo o vapor (aquele que vende a droga) no ponto. Perceberam que Jadson firmou uma venda. Estavam em carro descaracterizado, realizando campana. Marcos, ao visualizar a chegada da polícia, gritou "é polícia, é polícia". Marcos foi preso e Jadson empreendeu fuga. Localizaram uma sacola contendo maconha, cocaína e crack no local me que Jadson se evadiu. Jadson estava na função de vapor e Marcos na de olheiro. Jadson já era pessoa conhecida no tráfico. Marcos foi a primeira vez, embora já tenha sido visto na localidade, que é conhecida como ponto de tráfico. Não havia denúncia específica acerca da pessoa dos Réus. A localidade é conhecida como ponto de tráfico e foi uma operação de rotina. Em poucos minutos de campana já foi possível presenciar a venda de droga para um usuário. Visualizaram Jadson vendendo drogas para um usuário e Marcos realizando a função de olheiro. A sacola de drogas estava com. Jadson em mãos e, quando viu que era a polícia, largou a sacola sobre uma caixa d'água. As drogas dentro da sacola estavam acondicionadas e fracionadas para mercancia. Marcos, indagado informalmente, confirmou que Jadson estava realizando o tráfico de drogas. Marcos disse que estava na localidade esporadicamente. Marcos disse que estava na função de outra pessoa, substituindo um outro olheiro. Teria recebido uma porção de drogas e um pouco de dinheiro para realizar tal função naquele dia. Não se recorda se mencionou se foi a primeira vez. A campana durou em torno de uns cinco minutos. Apenas prenderam Marcos porque estavam em dois policiais e Jadson se evadiu. Não sabe se Jadson estava trabalhando na feira. Conhece Jadson pessoalmente em decorrência de outras abordagens.

Em solo policial, o condutor e testemunha NIVALDO HEROMDINO BORGES disse que "Que, é policial civil em exercício na chefia do 01º Distrito Policial de Cubatão. Que, na data de hoje em operação pelo Deinter 6, visando o combate ao tráfico de drogas na região, foram até o local dos fatos, este de conhecida prática de tráfico de entorpecentes, visto que em datas pretéritas já foram realizadas diversas prisões naquele local pela prática do referido crime. Que ao chegarem ao local em viatura descaracterizada, permaneceram de forma velada há cerca de trinta metros aproximadamente observando o movimento no local, onde já haviam dois indivíduos parados, porém afastados um do outro, sendo que um deles de nome Jadson, já é um velho conhecido dos policiais, por motivos de ter sido autuado em flagrante delito anteriormente pela prática de tráfico de drogas e o outro trata-se do indiciado Marcos. Que, enquanto observavam a movimentação no local, um terceiro indivíduo se aproximou de Jadson, o qual retirou do interior de uma sacola plástica algo que aparentemente seria entorpecentes e deu ao indivíduo, sendo que Marcos permanecia observando tudo atentamente de longe, momento em que os policiais decidiram proceder com a abordagem dos suspeitos, entretanto, Marcos que estava mais afastado de Jadson, e observando tudo atentamente, ao ver a aproximação do depoente e seu parceiro, gritou as seguintes palavras "é polícia, é polícia", instante em que Jadson que estava com a sacola em mãos acabou dispensando o objeto no chão e passou a correr e, o outro indivíduo desconhecido que seria o usuário também conseguiu correr em sentido contrário ao do primeiro e, ambos conseguiram se evadir do local, porém Marcos que anunciou a chegada dos policiais tentou se evadir de forma dissimulada como se nada tivesse acontecido, porém foi contido ali mesmo no local. Que ao verificarem o interior da sacola plástica dispensada por Jadson, encontraram os entorpecentes relacionados no boletim de ocorrências, os quais estavam todos embalados em pequenas porções e prontos para a venda em varejo. Que, ainda pelo local dos fatos, indagaram Marcos Araújo dos Santos, porque delatou a chegada dos policiais, tendo o mesmo informado que é usuário de drogas e que na data de hoje ao ir comprar entorpecentes, recebeu a proposta de um indivíduo de vulgo "neguinho", demais dados não sabe informar, o qual estava naquele local, e disse que precisava se ausentar para tomar um café rápido e que era para ele ficar observando uma eventual chegada de policiais e gritar avisando, sendo que receberia a quantia de dez reais para isso, tendo aceitado a proposta e enquanto estava no local a polícia chegou e conforme combinado gritou avisando da chegada da polícia e, ao tentar sair

do local, foi detido e trazido para delegacia. Que diante dos fatos, Marcos Araújo dos Santos, foi conduzido até esta delegacia bem como os entorpecentes deixados no local por Jadson. Que, realizaram buscas durante o registro da ocorrência na tentativa de localizar Jadson, porém até o término do registro não foi possível sua localização" (fls. 09/10).

Em Juízo reiterou a narrativa prestada em solo policial, corroborando com a versão de seu colega Albino.

Em solo policial, o acusado MARCOS ARAUJO DOS SANTOS disse que "Que, é usuário de drogas. Que, na data de hoje foi até o local dos fatos comprar drogas para seu consumo pessoal. Que, ao chegar no local, um indivíduo que conhece pelo apelido de "neguinho" estava no local como olheiro observando para que se eventualmente algum policial se aproximasse gritar. Que, "neguinho" disse ao interrogando que precisava se ausentar para tomar um café em uma padaria e que retornaria alguns minutos depois, sendo que ofereceu ao interrogando dez reais para que ficasse ali alguns minutos vigiando caso a polícia chegasse. Que aceitou tomar conta do local por alguns minutos e, enquanto estava observando notou a presença de policiais, porém foi detido e trazido até esta delegacia. Indagado sobre a pessoa de Jadson, afirma não conhecer e que era a primeira vez que foi aquele local. Indagado se deseja falar mais alguma coisa sobre os fatos, afirma que reserva-se ao direito Constitucional de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas em juízo" (fls. 13/14).

Interrogado em Juízo, disse que foi a primeira vez que foi até o local. Não conhecia ninguém. Conhecia o rapaz que ficava na "biqueira", chamado "Neguinho". Foi para o local para comprar drogas. Pediu 2 reais para comprar cachaça. O tal "Neguinho" disse que lhe daria 10 reais se ficasse algum tempo em seu local, pois iria na padaria comprar café. Depois de uns 10 ou 15 minutos passou um carro de polícia. Gritou "é polícia". Tentou ir até a padaria para chamar o "Neguinho", foi então que veio o policial. Foi algemado e levado para a delegacia. Não conhecia ninguém na localidade. Sabia que ficaria como olheiro no lugar de "Neguinho" naquela "biqueira". Foi a primeira vez que fez isso. Não conhece Jadson pois não mora na localidade. Conhecia apenas o "Neguinho". Quem estava com a sacola de drogas era Jadson.

Interrogado em Juízo, o acusado JADSON PAULO DA SILVA confessou a prática do tráfico de drogas. Foi a primeira vez que realizou tal atividade. Já tinha sido levado para a delegacia por ser usuário. No dia ganhou R\$ 150,00 para trabalhar na localidade até o meio-dia.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que os réus praticaram o crime descrito na denúncia, pois as versões apresentadas pelos Réus não encontram eco no manancial probatório, quedando-se isoladas.

Ademais, a comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela (art. 158 do CPP).

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (STJ, REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

E, a despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais civis deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade

administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais” (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perluastra que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, “a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação” (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98). A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais – caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) –, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP).

Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes.

Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar os acusados – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido –, soa mais que suficientes para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL.

CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp

875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); “...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, “o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente aos acusados a prática do crime descrito na denúncia, não havendo, portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos. Dúvida não há acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados.

Os relatos comprovam a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sobretudo porque se trata de delito de tipo misto alternativo, em que a prática de apenas um dos verbos constantes no preceito primário é bastante para a sua caracterização.

Nos termos do art. 28, § 2º da Lei de Regência, notadamente as condições em que se desenvolveram as ações criminosas, denota-se que os acusados, de forma deliberada, guardavam e tinham em depósito drogas – verbos nucleares do preceito primário contido no art. 33 -, em elevadíssima quantidade, que seriam distribuídas pelo estado, pelo que é nítida a existência do elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que os comportamentos perpetrados pelos réus se amoldam perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Cumprе ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar – que praticados isolada ou conjuntamente, implicam o cometimento de um crime único, ou seja, basta a prática de apenas uma dessas condutas para que o delito em tela consumar-se. Assim, o ato de “guardar” é apenas umas das condutas que se subsumam ao tipo penal. Sendo desnecessário que os réus sejam encontrados no momento que realizam a comercialização do entorpecente, mesmo porque, esse ato, via de regra, se desenvolve na clandestinidade e, no caso em tela, os acusados foram abordados em razão de um patrulhamento policial.

Logo, é inviável se cogitar a absolvição por falta de provas ou negativa de autoria dos acusados em relação à imputação da prática do delito em comento. Igualmente não há que se falar em atipicidade da conduta.

A tese de desclassificação para o art. 37 da Lei de Regência deve ser afastada em relação ao Réu Marcos, igualmente, isto porque no tráfico de drogas existem diversas funções na referida associação e que são divididas de forma a alcançar o desiderato principal.

Ora, dentre várias funções encontradas podemos citar o gerente, o passador, o radinho, o fogueteiro, a mula, o armeiro e também o denominado “olheiro”, que era exatamente a função do Réu.

Destarte, se todos contribuem de alguma forma para o tráfico e fazem parte da referida associação, em verdade são coautores do delito. Com efeito, o intuito do legislador ao adotar no tipo penal do art. 37 da Lei 11.343/06, a teoria pluralista/pluralística não foi de alcançar o referido olheiro, pois este é coautor da conduta descrita no art. 33, mas, sim, aqueles que normalmente não integram a associação em suas diversas funções hierárquicas – mas acabam colaborando com informações que são consideradas estratégicas para o exercício da narcotraficância, notadamente aquelas que informam sobre futuras incursões policiais nas localidades do tráfico ou prestam colaboração de outras naturezas, sobretudo informacionais.

Assim, considerando tudo que foi exposto, isto é, as circunstâncias que se desenvolveram os fatos, aliados com as informações prestadas em Juízo pelas testemunhas, não restam dúvidas da materialidade do delito praticado pelos Réus. De mais a mais, inexitem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento dos Réus, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação dos acusados por infração ao artigo 33, “caput”, da lei nº 11.343/06.

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

IV.I - Em relação ao réu MARCOS ARAUJO DOS SANTOS:

Na primeira fase da dosimetria penal, analisadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.ª ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286). Significa dizer que o legislador explicitou no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, transformando-as em preponderantes. Destarte, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 42 c/c art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: a grande quantidade de droga apreendida 26 porções de maconha (peso bruto - 90g), 58 pedras de "crack" (peso bruto - 35g) e 148 pinos contendo cocaína (peso bruto - 230g), autoriza uma maior reprovabilidade da conduta do réu, razão pela qual aumento a pena-base. b) Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes. c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o *modus operandi* (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são neutras, na medida em que inerente ao tipo penal. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado não transcendem à espécie, embora reprováveis. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a atenuante da confissão, que foi espontânea e voluntária (art. 65, inc. III, alínea "d" do CP e súmula 545 do STJ). Assim, atenuo a pena em 1/6, totalizando a intermediária em 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, a teor da súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase da dosimetria penal, de acordo com o constante dos autos, o réu é primário e não portada antecedentes (fl. 27). Embora não tenha comprovado ocupação lícita, não foi demonstrado durante a instrução criminal que estava se dedicando a atividades criminosas ou pertencia a organização criminosa - ônus que competia à acusação (art. 156 do CPP) -. Portanto, possível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11343/06, sob pena de se esvaziar por completo a aplicação da causa redutora e de violação dos princípios da presunção de inocência e do *in dubio pro reo*.

Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou a participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra *in dubio pro reo*" (STF, HC 103225-RN, 2ª T. rel. Min. Joaquim Barbosa, 11.10.2011, v.u). No mesmo sentido, também do c. STJ: HC 185331-RJ, 5ª T. rel. Min. Jorge Mussi, 14.02.2012, v.u).

Levando-se em consideração as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, notadamente a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, diminuo a pena no patamar de 1/3 (nesse sentido: STF com repercussão geral no ARE 666.334,

rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06/05/2014).

Reprimenda definitiva, ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três reais) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto ausente informações acerca da situação econômica do Réu (art. 49, § 1º c/cart. 60 do CP).

Por sua vez, com relação à almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16.02.2012, com efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena.

Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Nessa linha, insta consignar entendimento recentemente exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de julgamento do HC 118.533, por maioria de votos, decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06), por veemente desproporcional.

Tendo em vista as condições pessoais do acusado e natureza do ilícito praticado, consoante acima observado, é o caso de conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos - por igual período ao da pena privativa de liberdade -, consistentes na prestação de serviços à comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e à limitação de fins de semana, inexistindo razão impeditiva a tal. Por fim, em caso de descumprimento das penas alternativas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda imposta (art. 33, § 1º, alínea "c" e § 2º, alínea "c"), frente ao quantum fixado e às condições pessoais do réu, aqui já consideradas.

IV.II - Em relação ao réu JADSON PAULO DA SILVA:

Na primeira fase da dosimetria penal, analisadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.ª ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286). Significa dizer que o legislador explicitou no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, transformando-as em preponderantes. Destarte, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 42 c/c art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: a grande quantidade de droga apreendida 26 porções de maconha (peso bruto - 90g), 58 pedras de "crack" (peso bruto - 35g) e 148 pinos contendo cocaína (peso bruto - 230g), autoriza uma maior reprovabilidade da conduta do réu, razão pela qual aumento a pena-base. b) Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes. c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são neutras, na medida em que inerente ao tipo penal. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado não transcendem à espécie, embora reprováveis. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a atenuante da confissão, que foi espontânea e voluntária (art. 65, inc. III, alínea "d" do CP e súmula 545 do STJ).

Assim, atenuo a pena em 1/6, totalizando a intermediária em 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, a teor da súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Ademais, na terceira fase, malgrado a primariedade (fls. 119-120), não há como se aplicar a redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº. 11.346/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga encontrada, desvelando não se tratar de mercancia miúda ou esporádica. Outrossim, existe prova de que se dedicava à atividade regular da narcotraficância e pertencia à organização criminosa, a indicar envolvimento sério e detido com o meio, em decorrência do modus operandi da conduta e do depoimento dos policiais que efetuaram a abordagem. Com efeito, os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos ao afirmarem que Jadson era conhecido no meio policial, inclusive como sendo um "gerente do tráfico", causando estranheza trabalhar como "vapor" na ocasião do flagrante. Não bastasse isso, o Réu, em interrogatório, disse que fazia "uns 2 ou 3 anos que não trabalhava mais com isso", a denotar seu envolvimento com a mercancia espúria.

Cediço é que esse privilégio somente se aplica ao neófito, aquele que, sendo primário, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, absolutamente, não se cuida aqui.

Nesse sentido, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a incidência de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena, bem como a fração a ser aplicada. Incidência do enunciado 7 da Súmula deste STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguia do preenchimento dos requisitos legais. 3. A ausência de particularização dos artigos supostamente violados, inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, Ag Rg no Agravo em Recurso Especial nº 628.686 MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/02/2015, pub. em 02/03/2015).

Assim, estabeleço a pena final do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica dos acusados (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49). Diante da primariedade e do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime semiaberto (artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b" do Código Penal).

Ademais, o regime inicial deve ser o semiaberto, na hipótese dos autos, pois as circunstâncias elencadas no art. 59 são positivas e o numerário de reprimenda é compatível com o regime intermediário, forte na aplicação do art. 33, § 2º, "b", sendo ele, para o caso em espécie, o mais adequado frente aos propósitos de repressão, retribuição, ressocialização que, como visto, devem ser observados, a despeito da extensão da pena carcerária aplicada e da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, não autoriza a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal) nem mais gravoso, como o fechado. Com efeito, em que pese a gravidade do delito

seja por deveras considerada, tal ponderação já foi fixada pela legislação ao delimitar os parâmetros da pena, não podendo agora a opinião do julgador se firmar sobre esse pilar para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas nº 718 e 719 do STF).

Deve-se observar a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal dispõe: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". A ementa do acórdão que resolveu o Recurso Extraordinário 641.320, na parcela que interessa ao presente caso, tem o seguinte teor:

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.5.16).

Pelo mesmo motivo, e ainda em virtude do quantum da pena corporal aplicada, os réus não fazem jus à substituição da pena carcerária por restritiva de direitos (cf. artigo 44, incisos I e III, do Código Penal). Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

V – PERDIMENTO DE BENS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Amplamente demonstrado, que os bens apreendidos nos autos, eram utilizados para a prática de tráfico de drogas, de rigor o decreto de perdimento dos mesmos.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 08 e 113/114) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

VI – DA INAPLICABILIDADE DO ART. 387, § 2º DO CPP

Consoante precedentes do TJSP (HC 0122573-89.2013.8.26.0000 e HC 0159595-84.2013.8.26.000), o tempo de prisão cautelar não poderá ser considerado para efeito de progressão de regime, ante a necessidade de exame dos requisitos subjetivos.

Ademais, a Lei nº 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387, do CPP, não pode ser aplicada, eis que inconstitucional.

Com efeito, referida lei desrespeita a garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e causa inquietações quando à segurança (prevista na cabeça do art. 5º, da CF). O devido processo legal, no âmbito penal, pressupõe a existência de uma fase de conhecimento e outra fase de

execução da pena. Antecipar a execução da pena, para a fase de sentença, é tumultuar o feito e usurpar a competência do Juízo das Execuções Criminais. O devido processo legal exige, para a progressão de regime prisional, a observância das normas instituídas pelos arts. 110 a 119 da LEP (Lei nº 7.210/84). Somente a concentração dos feitos a que eventualmente responde o réu, na Vara das Execuções Criminais, permite a aferição de requisitos como: a) inexistência de condenação superveniente; b) bom comportamento carcerário; c) aqueles, estabelecidos no artigo 114, I a II, LEP; d) os estabelecidos no art. 115, I a IV, LEP; e) a inexistência das hipóteses trazidas pelo art. 118, I a II e parágrafos, LEP. Estabelece o Código Penal que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas aspectos quantitativos, relativos à quantidade de pena in concreto estabelecida pela sentença (previstos nos art. 33, § 2.º, letras "a", "b" e "c", do CP), mas também eventual reincidência do acusado e circunstâncias judiciais (consoante estabelece o art. 33, § 3.º, do CP). Significa dizer que a quantidade de pena não é o único critério para a fixação do regime inicial.

Pois bem. O art. 387, § 2.º, do CP estabelece que "o tempo